

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL

Señores:
Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE.....
E.S.D.

....., mayor de edad, domiciliado y residente en identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado y en ejercicio, con tarjeta profesional núm. del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me ha conferido el señor....., igualmente mayor de edad y vecino de....., en su condición de representante legal de la sociedad....., según certificación núm. de fecha, expedida por la cámara de comercio de....., ante ustedes, con todo respeto presento **Medio de Control de Controversia Contractual**, contra (entidad estatal), con domicilio en, representada legalmente por, o por quien lo reemplace o haga sus veces, para que, previos los trámites de que trata los Art. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), con citación e intervención del señor agente del ministerio público, se sirvan hacer en sentencia de mérito, las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

1. Que son nulas las resoluciones núms. de (fecha) y de fecha, expedidas por, mediante las cuales, respectivamente, se declaró la caducidad del contrato núm. de(fecha), celebrado entre la entidad demandada y mi representada, y se resuelve el recurso de reposición, confirmándose la anterior.
2. Condenase a (Nación, Departamento, Municipio,...) a pagar a(sociedad), el valor de los perjuicios de orden material (o a la reparación del daño causado) - daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados, los cuales ascienden, aproximadamente, a la suma de \$, (o de conformidad con lo que resulte probado en el proceso); monto que ha de ser actualizado en su valor.

3. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 192 y ss del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011)

HECHOS Y OMISIONES

1°. (La entidad) , celebró con (sociedad) el día de (mes) de [año],..... el contrato de obra pública núm., para la realización y ejecución de la obra cuyo objeto se detalla en el citado documento contractual.

2°. Los hechos “motivadores” de la declaratoria de caducidad del contrato, haciendo un análisis desapasionado y veraz respecto de lo realmente acontecido, no pueden ser imputables a título de dolo o culpa atribuibles a mi poderdante como contratista, pues, actuando en dicha calidad, comunicó oportunamente los inconvenientes que impedían el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas, como se demostrará sucintamente.

3°. En resumen, el acto administrativo acusado se hace fundar, para declarar ad libitum la caducidad, en los siguientes aspectos “Ni antes ni en el momento de suscribirse el contrato, el señor..... hizo observaciones o reservas respecto de las deficiencias de la información documental suministrada por..... (entidad contratante), que interfirieran el cumplimiento del contrato. Lo cierto es que el contratista no entregó la obra dentro del plazo estipulado”. Además, se arguyen otras situaciones que serán materia de análisis; concluyendo el ente contratante que es manifiesto el incumplimiento contractual, procediendo a declararlo y confirmarlo mediante las resoluciones cuestionadas.

4°. Si bien es cierto que la ley ha establecido este poder excepcional como prerrogativa de la administración pública contratante, que le permite ejercer la función que la erige, en concretas circunstancias, en juez de la oportunidad de la medida de sancionar con la declaratoria de caducidad de un contrato, no es menos cierto que esta potestad no es ilimitada ni que pueda ejercerse sin sujeción a las exigencias legales, específicamente a las establecidas en el artículo 18 de la ley 80 de 1993, que expresamente dispone “La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización,...” o que éste no se podrá ejecutar (inciso lo), la entidad contratante lo dará por terminado (resaltamos).

Es decir, la norma determina unas causales calificadas, atribuibles a título de dolo o culpa a la persona del contratista, que requieren de acreditación y plena comprobación.

5°. En el presente caso, no se da el incumplimiento por parte de mi representada en la entrega de la obra, que pueda calificarse como mora grave o atraso severo en la ejecución del objeto contratado, ni que se evidencie su necesaria paralización -pues el contratista se proveyó de los elementos y materiales requeridos en el contrato para llevar a cabo sus obligaciones-, ni que éste hubiese sido sancionado mediante la imposición de multas sucesivas, lo cual nos está denotando que la declaratoria de la caducidad es restrictiva y no discrecional. Por consiguiente, el rompimiento unilateral del vínculo contractual por la administración no estuvo precedido de un balance real y objetivo ni en un prudente juicio, acorde con la causal calificada, incurriendo en su declaratoria en irrefutables ligerezas y acomodadas interpretaciones, para evadir fácil y alegremente las propias responsabilidades contractuales que le caben, como se relaciona en el siguiente numeral.

6°. El incumplimiento se debió a hechos y actuaciones sólo imputables a la administración contratante, porque para la fecha en que inició la obra, el(ente administrativo) no había desocupado los espacios en donde debían ejecutarse los trabajos por el contratista. Con este grande inconveniente, la responsabilidad era única y exclusiva de la entidad contratante.

7°. La sociedad contratista, por conducto de su representante legal, le cursó comunicaciones a la parte contratante solicitándole la desocupación y entrega de los espacios, única manera de poder desarrollar sus labores contractuales. Además, le reiteró con oficio núm. del(fecha), el interés de culminación de la obra; es decir, se persistió en la ejecución del contrato, en observancia de lo dispuesto por el artículo 5°. de la ley 80 de 1993; sin embargo, la entidad no adoptó las medidas oportunas imprescindibles de solución, pues la desocupación continuó siendo paulatina.

8°. Ocurrido todo ello, la solución, en sabia ética administrativa, no era la declaratoria de caducidad, sino la ampliación del plazo del contrato principal, mediante la adición del mismo; por tanto, los motivos indicados en el acto acusado no son legales. Se está desvirtuando, entonces, el supuesto de hecho que sustenta la determinación cuestionada e impugnada en acción contencioso-administrativa.

9°. Los hechos que anteceden nos corroboran, en forma clara, entonces, que la contratista no incurrió en incumplimiento del contrato,

estableciéndose que existe ausencia de dolo o culpa por parte de ésta, quien agotó los pasos pertinentes para poder cumplir las obligaciones contractuales adquiridas; todo lo contrario, el supuesto incumplimiento por transgresión de las obligaciones del contratista constituyen una motivación, acomodaticia y caprichosamente esgrimida, que nos dicen a las claras que el ente administrativo no tenía objeto sobre el cual ejercer la potestad de caducar el contrato.

10°. Con la conducta administrativa de (entidad contratante) de declarar el incumplimiento del contrato por una causal legalmente inexistente, se le han ocasionado a la sociedad accionante serios y graves perjuicios económicos que, por negligencia e imprecisión, deberán ser reparados o indemnizados.

11°. El procedimiento gubernativo está agotado, y por tanto, se puede instaurar el presente medio de control.

12°. La sociedad, por intermedio de su representante legal, me ha conferido poder especial, amplio y suficiente para el ejercicio de este medio de control.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

- Artículos 2, 6, 25, 83 y 124 de la Constitución Nacional. por la finalidad propia de las normas constitucionales y como consecuencia lógica por serles inherentes, la, en su condición de entidad estatal contratante estaba obligada a observar, por ser de estricto cumplimiento, los preceptos supraleales invocados, y que le demarcaban el ejercicio justo, imparcial y de buena fe del poder o de la atribución excepcional de declaratoria de caducidad del contrato, atendiendo el principio de protección y efectividad de los derechos, así como el de acatar los presupuestos de orden sustancial que la Ley le señalaba para la expedición de los actos administrativos acusados. Las reglas que la Constitución establece en relación con la efectividad de los principios, derechos y deberes, son obligatorias en su cumplimiento; por ello, no es posible imaginar y mucho menos acolitar el desobedecimiento injusto de los preceptos supraleales.

La entidad estatal demandada, al declarar la caducidad del contrato, invocando una causal que, en su cualificación, no se materializaba, no cumplió sino que violentó los postulados de imparcialidad y de la buena

fe; como también desconoció los fines esenciales del Estado, extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones e infringiendo el derecho al trabajo de que gozaba la sociedad que represento, ante la existencia o nacimiento del vínculo contractual, y en tal condición le correspondía la especial protección del Estado.

Tamaña injusticia y arbitrariedad, exteriorizada mediante la expedición de los actos administrativos contractuales demandados, pone de manifiesto un atentado a la vigencia de un orden justo que debe generar responsabilidad patrimonial para el ente demandado por daños antijurídicos, de conformidad con el artículo 90 de la Carta Fundamental, en concordancia con los artículos 50 y 51 de la Ley general de contratación.

La vigencia de un orden justo, en el caso de marras, apunta al conjunto de normas que debe presidir la Conducta del Estado y de sus entidades; normas que fueron flagrantemente infringidas, como se ha expuesto y cuyos conceptos se concretarán como fundamento cuando se trate del desconocimiento del contrato y de la ley preexistente, en cuyos contextos debe armonizarse y comprenderse el presente concepto.

Cuando hacemos expresa alusión al contrato -cláusulas consideradas infringidas-, nos referimos al perfeccionado el [fecha] entre yla sociedad; y cuando se acota sobre la ley preexistente, hacemos expresa referencia a la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, al Código de Comercio y al Código Civil en los preceptos que regulan -respectivamente- el vínculo contractual o la actuación administrativa, vulnerados con el proceder administrativo de la parte demandada, en un concepto de violación correlativo con las disposiciones constitucionales que sustentan la conducta equivocada del ente estatal y su consiguiente quebrantamiento, porque no fueron acatados, observados ni cumplidos en la etapa de ejecución del contrato.

La actividad del ente administrativo por disposición de la ley ha de estar sujeta a realizar con mayor eficiencia la inversión, con derroteros y programas específicos, con apropiación presupuestal, que garanticen la seriedad y el cumplimiento de los contratos que celebre, en lo que atañe a no dar lugar a traumatismos que afecten el desarrollo de dichos programas y perjudiquen la persona del contratista, causándole agravios a ésta y lesionando sus derechos.

- Artículos 9°. -numeral 9°. 18 por aplicación indebida, 23, 26 -numerales 1°, 2° y 4°.., 28, 50 y 51 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007.

Ya quedó dicho, la causal esgrimida por la entidad contratante en el numeral de los considerandos de la resolución núm.....de [fecha] y la de su confirmación, y que hace consistir en que “no se entregó la obra dentro del plazo pactado”, por los hechos de la demanda, no tiene ningún asidero legal, incurriendo en un exabrupto jurídico al declarar la caducidad por un supuesto incumplimiento del contrato, producto de interpretaciones subjetivas y acomodaticias, que riñen contra la legalidad y son ajenas y no compatibles a las reales causales que, en su cualificación, preestablece y determina el artículo 18 del estatuto general de contratación. En otras palabras, la entidad estatal contratante, para declarar la caducidad, por un hipotético incumplimiento, no se fundó en ninguna de las causales previstas que, en su ocurrencia, generaban la terminación anticipada del contrato por tales motivos. O dicho de otro modo la sociedad que representó no incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales y menos que hubiese podido ocurrir por su culpa o dolo, mora grave o atraso severo en la ejecución de la obra que pudiera evidenciar su necesaria paralización, y mucho menos que hubiesen antecedentes de haber sido sancionado con anterioridad mediante la imposición de multas sucesivas por incumplimiento del objeto contractual. Por consiguiente, el rompimiento unilateral del vínculo contractual por la administración no estuvo precedido de un balance real y objetivo ni de un prudente juicio, acorde con las causales cualificadas.

Es el momento de decir, entonces, que el incumplimiento se debió a hechos y actuaciones sólo imputables a la administración contratante. Ésta, como dueña del objeto contractual, conoce mejor lo que con el contrato se pretende; pero aquí nace el desacuerdo con la persona del contratista en esa actividad connatural a la aplicación y ejecución del contrato, pues ella no justifica el cómo y el porqué contrató en las condiciones que se señalan a continuación, y que son, realmente, las causas generadoras de no haberse llevado a feliz término, en oportunidad, la ejecución del objeto contractual:

a) Para la fecha en que inició la obra, el (ente administrativo) no había desocupado los espacios en donde debían desarrollarse los trabajos por el contratista, habiendo dispuesto el interventor empezarla en el único espacio libre hasta ese momento, que equivalía a un área “entregada” del diez por ciento (10%) del área total. Con este grande inconveniente, es deducible que, desde el inicio, la obra no podía empezar a ejecutarse a cabalidad; ello es evidente.

b) Transcurrido un (1) mes de haberse empezado los trabajos, todavía estaba ocupado, aproximadamente, el setenta por ciento (70%) del área, lo cual obligó a la sociedad contratista, por conducto de su representante

legal, a cursar un oficio al interventor solicitándole la desocupación y entrega de los espacios. Prueba de ello es que no existe acta de iniciación ni recibo de obra, que debían suscribir conjuntamente, el contratista, el interventor y la entidad contratante, o sus representantes.

Estos inconvenientes, lógicamente, retrasaron la ejecución de los trabajos; y, por ello, la administración no podía aducir en su resolución de caducidad que “no se entregó la obra dentro del plazo estipulado”. Su deber era, en consecuencia, haber tomado las consiguientes medidas de control que garantizaran la ejecución del contrato, porque estaba demostrada la existencia de fuerza mayor o motivos ajenos a la voluntad de la accionante en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. En definitiva, las deficiencias no eran imputables al contratista. Estaba, por lo tanto, seriamente comprometida la ejecución del contrato en su totalidad, por motivos imputables tan sólo a la administración, que hicieron prácticamente imposible su cumplimiento por parte de la persona del contratista.

Pese a los inconvenientes relatados, en la medida de lo posible se vino ejecutando el objeto contractual, en las áreas que lentamente iban siendo desocupadas, sin que se lograran los fines propuestos, es perceptible entenderlo. Queda claro, entonces, que la contratista no incurrió en incumplimiento del contrato, lo cual evidencia ausencia de culpa por parte de ella.

Según lo dispuesto por los artículos 23 y 28 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 83 de la Constitución Nacional, en las actuaciones relacionadas con la contratación estatal deben aplicarse las reglas de interpretación establecidas y cumplirse los postulados de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos antes y durante la ejecución del contrato -principios que tienen proyecciones procesales-, lo que no acató la administración al declarar la caducidad del contrato, porque por ninguna parte se observa el sentido de seguridad, imparcialidad, eticidad, responsabilidad, honorabilidad ni voluntad de reconocer los derechos en las decisiones acusadas.

Y de conformidad con los artículos 26 -numerales 1°, 2° y 4°..., 50 y 51 del mismo estatuto contractual, al no procurar la entidad demandada con su actuar el cumplimiento de los fines de la contratación, ni la protección de los derechos del contratista, so pretexto de salvaguardar errónea e injustamente sus intereses, no lo hace ajustada a la ética y a la justicia, sus hechos y omisiones antijurídicos la hacen incurrir en responsabilidades de tipo patrimonial por las cuales debe responder. Los servidores públicos y las entidades estatales no pueden hacer sino lo que la Constitución, las leyes o los reglamentos les autoricen expresamente; y

cuando lo hacen en contrario a dichas disposiciones, por acción u omisión, además de responder disciplinaria, civil y penalmente, deberán indemnizar los perjuicios, esto es, la disminución patrimonial que se ocasione, la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista.

Así los hechos, la anulación de los actos administrativos demandados habrá de proceder, por cuanto la conducta de la entidad estatal no fue la más ortodoxa desde la perspectiva contractual, pues se observa contradicción e incongruencia entre lo resuelto y normas superiores de derecho, calificativo que también es viable para las contractuales, por ser ley para las partes. Y si con su contradictorio, arbitrario e injusto aplicado poder exorbitante le ocasionó a la sociedad accionante senos y graves perjuicios económicos, deberá resarcirlos o indemnizarlos; como así solicito se declare y condene, porque hubo una protuberante desviación de poder o de las atribuciones que le eran propias.

- Artículos 1602, 1603 y 1613 del Código Civil.

Estatuye el artículo 1602 que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Precepto infringido por [entidad estatal contratante] al declarar la caducidad del contrato sin que se hubieran dado las causales cualificadas que determina la Ley. La cláusula de caducidad pactada en el vínculo contractual, en consecuencia, fue mal aplicada; además, porque las causas legales, como ley para las partes, tenían que respetarse. Al no hacerlo así, la entidad demandada, no debe sujetar su proceder a los postulados de la buena fe; le corresponde al juez proteger los desequilibrios económicos y guardar el equilibrio de las cargas públicas, protegiendo al accionante de los abusos en la aplicación del poder excepcional, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia contencioso administrativa.

Analizada la conducta de la administración a la luz de los principios del derecho civil, también es evidente el desconocimiento del postulado previsto en el artículo 1602; extralimitación de atribuciones que debe generar responsabilidad patrimonial, por daño emergente y lucro cesante, acorde con las disposiciones de la legislación civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993. El atentado a la vigencia de un orden justo es notorio, concepto que debe armonizarse y comprenderse con el criterio expuesto en el numeral 1o. de este acápite.

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011)

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011)

4-Procesales Particulares:

Art. 141 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011)

PETICIÓN DE PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas, las siguientes:

1°. Los documentos que acompaño a la presente demanda y los allegados con posterioridad:

- a) Poder para actuar y con el cual se acredita la personería del suscrito.
- b) Certificación de la Cámara de Comercio de , sobre constitución y gerencia de (sociedad contratista).
- c) Fotocopias auténticas de la resolución núm. de fecha, con su constancia de notificación, mediante la cual se declaró la caducidad del contrato; y de la resolución núm., de (fecha), con su constancia de notificación, confirmatoria de la anterior, proferidas por (representante legal de la entidad contratante); actos acusados.
- d) Copia [o fotocopia auténtica] del contrato administrativo de obra pública núm. ..., de fecha , suscrito y perfeccionado por las partes.
- e) Copias de los oficios núms. y, fechados, suscritos por el representante legal de la sociedad y remitidos a la entidad contratante, donde aparece firma y radicado de recibido.
- g) Documentos que demuestren gastos
- h) Las demás procedentes y pertinentes

2°. Que se oficie a (entidad contratante), para que con destino al proceso envíe, debidamente autenticados, los siguientes documentos:

a) Los antecedentes administrativos relacionados con el contrato núm., de fecha, celebrado entre la accionante y el citado ente administrativo, incluyendo todos y cada uno de los documentos que conforman el expediente.

b)

3°. Que se oficie a la Superintendencia Bancaria, para que con destino al proceso certifique sobre los intereses legales y moratorios.

4°. (Testimoniales)

5°. (Pericial).....

COMPETENCIA Y CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 152 numeral 5 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), corresponde a este Honorable Tribunal conocer de este proceso en primera instancia, por la naturaleza de la acción, en razón del lugar donde debió ejecutarse el contrato, y la cuantía que se deriva de la misma, determinada de acuerdo al Art. 157 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) y cuya estimación razonada es:

CONCEPTO POR PERJUICIOS MATERIALES

VALOR

1. Daño emergente:

- | | |
|--|----|
| • Impuesto de timbre del contrato. | \$ |
| • Valor de la publicación. | \$ |
| • Valor sufragado para constituir la póliza de cumplimiento. | \$ |
| • Valor del contrato dejado de | \$ |

percibir por la sociedad que represento como contratista, conforme a la cláusula del mismo.

Costos y gastos no reembolsados

• \$ _____
\$ _____

Subtotal perjuicios daño emergente

La anterior cantidad ha de actualizarse por causa de la depreciación de la moneda [o pérdida de poder adquisitivo]; mediante la aplicación de la fórmula de las matemáticas financieras; desde la fecha de expedición de la resolución número....., fechada..... por medio de la cual se aprobaron las garantías exigidas al contratista hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin a la presente demanda, lo anterior se proyecta a la fecha así:

***Fórmula a utilizar:**

$$\text{Valor. Actual} = (\text{IPC. FINAL} / \text{IPC.INICIAL}) * \text{Capital}$$

2. Lucro cesante:

Al no haber percibido el dinero [en la cantidad sin actualizar] en la oportunidad contractual establecida, produce un interés moratorio que debe resarcirse por la entidad contratante desde la fecha de la declaratoria de caducidad del contrato hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia (la tasa de interés será la fijada trimestralmente por la superfinanciera), lo anterior se proyecta a la fecha así:

RESUMEN DE CONCEPTOS

VALOR

1. Daño emergente actualizado: \$ _____
2. Lucro cesante: \$ _____

Suma total de los Perjuicios \$ _____

NOTIFICACIONES

[Entidad demandada], en:

[La sociedad demandante, por medio de su representante legal], en:
.....

[Apoderado], en:

ANEXOS DE LA DEMANDA

Se anexan a la presente demanda, los documentos enunciados en el acápite de pruebas; los poderes para actuar y las copias en medio magnético y físico de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, en este caso al _____, al Agente del Ministerio Público Delegado y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

CC. No.....de.....
T.P No.....del C S J